

1501567-09.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... dos fatos, conhecido como ponto de trafico, que ele demonstrou nervosismo ao ver a viatura, ensejando a abordagem, que em seu poder foram encontrados os três pinos de droga e que ele indiciou o local onde escondia o restante das drogas, em um monte de areia, tendo ainda confessado informalmente que praticava o trafico no local. Vale ressaltar, por oportuno, que os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501567-09.2021.8.26.0599 - Controle nº 2021/001166

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2278255/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 20778843 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2846/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2278255 - 02º D.P. PIRACICABA, 2846/21/922 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS RAFAEL PONCE TELES

Réu Preso

Aos 15 de março de 2022, às 15:15h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 em razão da pandemia do coronavírus, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dra. FERNANDA GUIMARÃES ROLIM BERRETA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: DOUGLAS RAFAEL PONCE TELES - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: GC PEDRO CARLOS GIRHÃO - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: GC JOEL VASCONCELOS DE LIMA-COMUM - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foi colhido o depoimento da testemunha GC PEDRO CARLOS GIRHÃO.

Dada a palavra à Dra. Promotora, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha GC JOEL VASCONCELOS DE LIMA, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Dada a palavra à Defesa, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha GC JOEL VASCONCELOS DE LIMA, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Após, o réu DOUGLAS RAFAEL PONCE TELES foi devidamente interrogado.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ.

A seguir, pela MM^a. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pela Dra. Promotora de Justiça foi dito o seguinte: "DOUGLAS RAFAEL PONCE TELES, já qualificado nos autos em epígrafe, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pelas condutas delituosas descritas na exordial acusatória de fls. 69/71. O processo teve andamento regular. Devidamente notificado (fls. 86), o réu apresentou sua defesa preliminar (fls. 90/94), sendo a denúncia recebida (fls. 95/97). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu, por fim, interrogado. Em síntese, o necessário. Passa-se à manifestação. A prova produzida impõe a procedência da ação penal. A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, fotografia de fls. 29 e pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 115/117. A autoria do crime de tráfico de drogas descrita na denúncia restou também suficientemente comprovada. O guarda municipal Pedro Carlos Girão, confirmando suas declarações prestadas na fase investigativa, narrou que estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando se depararam com o réu parado na esquina., local já conhecido por intenso comércio de droga.. Afirmou que o acusado, ao avistar a viatura policial, apresentou certo nervosismo e saiu andando. Diante da fundada suspeita, realizaram a abordagem, sendo que em revista pessoal foi localizado no bolso de sua bermuda a quantia de R\$ 20,00 reais em notas diversas e 3 micro tubos de substância aparentando ser cocaína. Esclareceu que, em entrevista informal, o acusado confessou que estava vendendo drogas no local e que vendia cada micro tubo a R\$ 10,00 reais, sendo que o dinheiro que estava em sua posse derivava da venda de drogas no local. DOUGLAS ainda indicou onde escondia o restante da droga que seria comercializada e apontou um monte de areia, que ficava próximo do local da abordagem, onde foram localizados mais 82 micro tubos de cocaína, idênticos aos que foram encontrados na posse de DOUGLAS. No mesmo sentido foram as palavras do guarda municipal Joel Vasconcelos de Lima, ouvido apenas na fase policial. Por fim, interrogado, o réu negou o crime descrito na denúncia. Disse que comprou no local dos fatos três pinos de drogas para seu uso e, logo depois da compra, foi abordado pelo guarda municipal, tendo o traficante que lhe vendeu a droga corrido da viatura. Disse que , para colaborar com a Guarda, indicou onde estavam os demais entorpecentes apreendidos, alegando que sabia o local porque morava ali próximo. Sua negativa, entretanto, não tem como prevalecer, eis que restou isolada no álbum probatório. De fato, insta ressaltar que na fase inquisitiva, ao contrário do alegado em Juízo, o acusado confessou a propriedade de todo o entorpecente apreendido, contrariando assim sua versão judicial. Outrossim, é certo que os guardas municipais foram uníssonos ao afirmar que viram o acusado no local dos fatos, conhecido como ponto de trafico, que ele demonstrou nervosismo ao ver a viatura, ensejando a abordagem, que em seu poder foram encontrados os três pinos de droga e que ele indicou o local onde escondia o restante das drogas, em um monte de areia, tendo ainda confessado informalmente que praticava o trafico no local. Vale ressaltar, por oportuno, que os depoimentos prestados pelos guardas são plenamente válidos como meio de prova, se produzidos sob o crivo do contraditório e se estiverem coerentes com as demais provas produzidas, como ocorre no caso em tela. Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Ministro Arnaldo Esteves Lima, no julgamento do HC nº 123293/MS, publicado no dia 16/11/2009, do qual se extrai o seguinte trecho: O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. Ainda nesse sentido: PROVA - TESTEMUNHA - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que

inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Inexistência de dúvida que justifica o decreto condenatório - O testemunho de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como de qualquer outro testemunho - Merecem credibilidade e se de acordo ou conformidade com as demais provas, justificam um decreto condenatório - Entendimento - Precedentes - Recurso parcialmente provido. (Apelação n. 990.08.180251-1 - Birigui - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton de Oliveira Neves - 04/05/2010 - 8640 - Unânime). (Grifei). Destarte, tem-se que o crime descrito na denúncia restou bem comprovado, sendo a condenação de rigor. Quanto à aplicação da reprimenda, verifica-se que as circunstâncias judiciais são neutras. Na segunda fase, observa-se que o réu é reincidente específico (autos nº 0007716-25.2019 - fls. 72/73), porém esta circunstância agravante pode ser compensada com a atenuante da confissão. Na terceira fase, ante a reincidência específica, inaplicável o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Requeiro, por fim, seja decretado o perdimento do valor apreendido com o acusado, consistente em R\$ 20,00 (vinte reais), com fulcro nos artigos 61 e 63, ambos da Lei nº 11.343/2006. Diante do exposto, o Ministério Público requer e aguarda a procedência da ação, com a condenação do acusado nos exatos termos da exordial".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma como descrito na exordial. Encerrada a instrução probatória nesta data, a Defensoria Pública entende, EM SEDE PRELIMINAR, que as provas obtidas nos autos, em especial as substâncias entorpecentes encontradas pelos Guardas Municipais são ilícitas, eis que a abordagem e a prisão do acusado decorreu de autoridades incompetentes. Com efeito, de acordo com a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 144, § 8º, os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, sendo o referido dispositivo reproduzido de forma idêntica na Constituição do Estado de São Paulo. Portanto, de acordo com as referidas disposições, vislumbra-se que a atual ordem jurídica contempla quais são as específicas atribuições da Guarda Municipal, órgão ao qual incumbe a defesa e proteção dos bens, serviços e instalações em âmbito municipal. Ou seja, as Guardas Municipais não têm status de polícia ostensiva, função esta que cabe a Polícia Militar do Estado de São Paulo. No caso em tela, verifica-se que houve flagrante invasão de competência material, pois a Guarda Municipal atuou como se fosse polícia ostensiva. Nesse aspecto, cumpre mencionar que os Guardas, de forma ilegal, abordaram o acusado sem que qualquer situação de flagrante delito estivesse visível, ainda que fossem autoridades incompetentes para tanto. Essa função, todavia, não incumbe aos Guardas Municipais, mas à Polícia Militar. Na realidade, os Guardas Municipais, diante do fato, deveriam ter acionado o órgão competente para atender à ocorrência. Na atual ordem jurídica, existe a polícia ostensiva, representada pela Militar, e a polícia judiciária, representada pela Civil. Assim, os Guardas jamais poderiam ter atuado como se possuíssem aptidão para tanto. Há, no caso em comento, evidente invasão de competência administrativa, de índole constitucional, o que enseja a ilegalidade do ato (prisão em flagrante) e de todas as provas carreadas aos autos, visto que elas são provenientes, todas, de atos dos aludidos Guardas Municipais que atuaram como polícia ostensiva, em flagrante desrespeito às suas atribuições constitucionais. Neste sentido, já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "Ação Penal - Desarmamento - Guarda Municipal - Ação de polícia ostensiva - Ilegalidade - Apelo provido para absolver o acusado." (TJSP, ACri nº 990.09.226504-0 - 2ª câmara de direito criminal - origem: Piracicaba/SP, julg. 1º/02/10); "Apelação Criminal Tráfico de entorpecentes - Prisão dos réus efetuada por Guardas Municipais - Afirmação dos servidores da realização de campanha para confirmar o crime - ilegalidade da ação reconhecida - Admissão, no caso presente, da existência de prova que contamina a ação penal Apelo provido para absolver os réus." (TJSP, ACri nº 0032340-54.2011.8.26.0602 - 2ª Câmara de Direito Criminal - origem: Sorocaba/SP, julg. 12/11/2012). Inclusive, nas palavras do Ilustre Desembargador relator da Apelação Criminal nº 0032340-54.2011.8.26.0602, cuja ementa se encontra acima transcrita e

que teve origem na Comarca de Sorocaba/SP, onde também é usual que a Guarda Municipal exerça as tarefas da polícia ostensiva, defendeu, com grande propriedade, o Dr. Almeida Sampaio: "Fica delineado, de maneira bastante evidente, portanto, que, dentro da divisão das atribuições das Polícias, somente à Militar é outorgado constitucionalmente o poder de exercer o policiamento ostensivo, cabendo tão-somente à Guarda Municipal a proteção de seus bens, serviços e instalações". E ainda: "Em razão da Constituição de 1988, todos os entendimentos jurisprudenciais e a legislação que não se coadunem com a norma perderam sua validade. Enquanto não ocorrer alteração dos dispositivos acima transcritos, fica rejeitada a validade da ação de Guarda Municipal que, em ação de policiamento ostensivo, efetua diligências para prender eventual traficante.". Por fim, é cediço que qualquer pessoa do povo pode efetuar a prisão em flagrante e, por isso, em tese, a Guarda Municipal também teria esse poder. Contudo, o que não é permitido é que uma Instituição que tem por função a proteção do patrimônio público se utilize de um poder que não possui e atenda ocorrências, realize investigações e efetue abordagens, a fim de efetuar uma prisão em flagrante. Todavia, se superada a preliminar, QUANTO AO MÉRITO, as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao denunciado. Isso porque, como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz necessário um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um decreto condenatório. Nesta data, a testemunha Pedro, GCM, declarou que estavam em patrulhamento quando se depararam com um indivíduo parado na esquina. Ao ver a viatura, ele demonstrou nervosismo e saiu andando, por isso foi abordado. Encontraram com o réu 03 porções de cocaína e dinheiro. Ele confessou informalmente o tráfico de drogas e indicou onde estava o restante do entorpecente. O restante das drogas, idênticas àquelas que estavam com o réu, foram localizadas neste local. A região onde o réu estava é conhecida como ponto de tráfico. Ele estava sozinho. O réu, em interrogatório, declarou que estava indo embora da residência de sua tia e parou no ponto de tráfico e comprou 03 porções de cocaína para seu consumo, recebendo R\$ 20,00 de troco. Logo depois, foi abordado pela GCM e o traficante correu. Disse aos Guardas que portava 03 pinos em suas mãos para seu consumo pessoal. Para colaborar com os Guardas, disse onde estava o restante do entorpecente. Sabia disso porque mora próximo ao local, mas não tem envolvimento com o tráfico de drogas. Conhecia os Guardas, mora próximo à base da GCM. Não tem nada contra os Guardas. Portanto, Excelência, verifica-se que o acusado nega a prática do tráfico de drogas, sendo que sua negativa deve ser considerada um elemento probatório, afastando-se qualquer juízo preconceituoso que se tenha contra ela, sobretudo porque não refutada pelas demais evidências dos autos. Isso porque, as provas produzidas pela acusação restringem-se, apenas, às palavras dos Guardas Municipais responsáveis pela prisão do acusado, as quais, todavia, devem ser recebidas com reservas. Com efeito, mister destacar, neste ponto, que a Defensoria Pública não pretende desqualificar a nobreza ou a honestidade de uma instituição responsável pela segurança patrimonial do Município ou negar a força probatória dos depoimentos dos agentes, embora seja inegável que eles, na grande maioria das vezes, ratifiquem em Juízo a versão apresentada quando da realização da prisão, inclusive como forma de convalidar o ato e seus respectivos efeitos. Sustenta a Defensoria Pública, na realidade, que os depoimentos dos agentes, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem servir de fundamento para a prolação de uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a busca da verdade processual. Aliás, em se tratando de delitos de drogas, o E. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não admitir as palavras de Policiais ou outros agentes de segurança como fundamento para uma condenação: "Assim, o que se verifica, é que a condenação foi amparada exclusivamente nas declarações policiais, o que se revela insuficiente. É que seus testemunhos tem qualificação e natureza diversas de qualquer outro. São relatos de agentes policiais, ou seja, a longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as teorizações jurídicas processuais de âmbito criminal não podem ignorar a realidade fática. O policial é o agente operacional da

repressão e não depõe com a imparcialidade das demais testemunhas, ainda que de modo inconsciente. Sua visão sobre os fatos, o seu entendimento sobre as circunstâncias que apurou, são do próprio sistema repressor, dos quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva proteger." (TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11 - grifado). Inclusive, no caso em pauta, verifica-se que, a despeito do depoimento dos Guardas, não existiam sequer denúncias prévias apontando o acusado como o responsável pelo tráfico de drogas na região e não foram avistadas condutas prévias que indicassem o envolvimento do acusado no tráfico de entorpecentes (p. ex., recebimento de dinheiro, entrega de objetos, etc.), além de não terem sido apresentados outros indivíduos como possíveis compradores das drogas e/ou testemunhas presenciais dos fatos. Ressalta-se, também, que grande parte dos entorpecentes, na realidade, não foram localizados sob a posse direta do réu, mas em um local aberto, de livre acesso a qualquer indivíduo. E a suposta confissão informal do acusado não foi confirmada em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a mera afirmação de que o local da abordagem seria um ponto de tráfico de drogas não é presunção absoluta de dedicação do réu à prática deste crime, eis que, nesses locais, circulam tanto indivíduos envolvidos com o comércio de entorpecentes quanto usuários dessas substâncias. Por fim, também é importante mencionar que, recentemente, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, em v. acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal, que somente a quantidade e variedade de drogas apreendidas com uma pessoa não são elementos suficientes para a caracterização do tráfico, sendo necessários outros fundamentos concretos que atestem o envolvimento do agente no comércio de entorpecentes

(Proc. 000843-44.2017.8.26.0559). Portanto, diante das provas produzidas, a absolvição do réu é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Entretanto, na hipótese deste E. Juízo afastar o pleito absolutório, requer-se, ao menos, diante das declarações do acusado em seu interrogatório, a DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. Isso porque, com a devida vênia, há de se reconhecer que não há nos autos indícios de que o acusado fosse comercializar as drogas apreendidas, sendo que, reitere-se, não foi verificado qualquer ato efetivo de mercancia dos entorpecentes. Assim, no máximo, o réu poderia ser responsabilizado por portar drogas para fins de consumo pessoal, pois não foi demonstrado cabalmente o intuito lucrativo, não bastando a simples apreensão do entorpecente em poder do acusado para se justificar uma condenação por tráfico. Vale observar, ainda, que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas em poder do réu nada diz quanto à sua destinação, eis que a quantidade necessária para a satisfação de um usuário é completamente variável. Para a configuração do crime de tráfico, não basta a simples apreensão da droga, sendo imprescindível a aferição de prova cabal da finalidade de mercancia dos entorpecentes por parte do réu, o que não foi o caso. Todavia, caso mantida a condenação pelo tráfico de drogas, requer-se, então, a APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, MESMO EM FACE DA REINCIDÊNCIA. Isso porque, ainda que considerado reincidente, vale lembrar que a Lei de Drogas, ao fixar como pena mínima, para o delito de tráfico, cinco anos de reclusão, prevendo, ainda, a causa de diminuição de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) para primários, acaba por valorizar, em demasia, o critério da reincidência. Desde, portanto, que presentes os outros requisitos para a aplicação da causa de diminuição (ou seja, não havendo elementos probatórios de que o réu se dedique ao crime, praticando-o com contumácia, e sem provas de que ele integre organização criminosas), é de se considerar que o peso atribuído à reincidência é superdimensionado em relação ao apenamento do agente primário, ofendendo, assim, o princípio da proporcionalidade, implícito no ordenamento constitucional do Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF). A aplicação da pena ao réu primário, presentes os demais requisitos legais, ensejaria a redução no patamar de 2/3, implicando a sanção de um ano e oito meses de reclusão. Ao réu reincidente, o mesmo fato representaria, pela ausência de aplicação da causa de diminuição, uma pena de 5 (cinco) anos. O peso da reincidência, portanto, é claramente desproporcional, pois o valor do fato

praticado é de aproximadamente 1/3 (um terço) da pena, sendo 2/3 (dois terços) aplicados em função da reincidência. Essa desproporção também é inconstitucional porque atribui, para a dosagem da pena, valor maior aos fatos pretéritos do que à própria acusação em questão. Aceitar-se como válida a ampliação ao infinito do peso da reincidência implica a aplicação do direito penal do autor e não do fato – punição fundada preponderantemente em quem o agente é (ou seja, em face de seus antecedentes) e não em função do ato por ele praticado. Como afirma Muñoz Conde: “A distinção entre Direito Penal do ato e Direito Penal do autor não é só uma questão sistemática, mas, também, e fundamentalmente, política e ideológica. Só o Direito Penal baseado no ato cometido pode ser controlado e limitado democraticamente (...) o Direito Penal do autor não permite limitar o poder punitivo do Estado e favorece sua concepção totalitária” (Teoria Geral do Delito – SAFE, p. 09/10). O direito penal do autor não se coaduna com o Estado Democrático de Direito e por isso suas impressões devem ser descartadas, inclusive pelo Juiz. No mesmo sentido: “O direito penal de autor não encontra guarida em nenhum sistema penal fincado no Estado de Direito, comprometido, que é, com a dignidade da pessoa humana e com a garantia de seus direitos fundamentais, e, sobretudo, em nosso ordenamento, onde a presunção vigente é, ao reverso do que se propugna com a referência a tal condenação, a de inocência.” (Min. Cezar Peluso em Voto Visto no RHC 81.057-8-SP). Por fim, nem se diga da impropriedade de se afastar uma regra legal (proibição da redução ao reincidente) em face de um princípio não explícito. Como afirma Fábio Konder Comparato, apesar de seu alto grau de abstração, os princípios são normas jurídicas e não simples recomendações programáticas ou exortações políticas. Mais ainda: trata-se de normas jurídicas de eficácia plena e imediata, a dispensar a intermediação de regras concretizadoras. Provocado ou não pelas partes, o juiz está sempre autorizado a aplicar diretamente um princípio ao caso trazido ao seu julgamento, por força do disposto no §1º do art. 5º, da Constituição (“O papel do juiz na efetivação dos direitos humanos”, in Direitos Humanos – Visões Contemporâneas, edição de Associação Juizes para a Democracia, 2001). Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer, no tocante à dosimetria da pena: (i) a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, ressaltando-se a pouca quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, sendo que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP são favoráveis ao acusado, ressaltando-se que a sua vida pregressa deve ser valorada somente na segunda fase, a fim de se evitar eventual bis in idem com eventual agravante da reincidência; (ii) a incidência, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão espontânea (ainda que informal ou extrajudicial), compensando-a com eventual agravante da reincidência, diante do caráter subjetivo e preponderante de ambas as circunstâncias; (iii) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como sustentado; (iv) seja fixado o regime menos gravoso do que o fechado para início do cumprimento da pena, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF – Pleno – HC nº 111.840/ES – rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e das súmulas nºs 269 e 440 do E. STJ; (v) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize, neste momento processual, a manutenção de sua prisão preventiva”.

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

DOUGLAS RAFAEL PONCE TELES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 12 de outubro de 2021, por volta das 19h08min, na Rua Professor Pedro Moraes Cavalcante, nº 15, Bairro Vila Cristina, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, trazia consigo e tinha em depósito, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 85

(oitenta e cinco) "eppendorfs" de cocaína em pó, com peso líquido de 25,5g (vinte e cinco gramas e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que guardas municipais estavam em regular patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram o acusado parado na via pública, o qual, ao visualizar a viatura, apresentou certo nervosismo e saiu caminhando de forma furtiva. Em razão disso, os agentes públicos procederam à abordagem e apreenderam na posse de DOUGLAS, especificamente no bolso de sua bermuda, 03 "eppendorfs" de cocaína em pó e a quantia trocada de R\$ 20,00.

Indagado, o réu admitiu aos guardas que estavam comercializando entorpecentes no local, que o valor em espécie que estava em sua posse era proveniente do tráfico e indicou o local onde havia homiziado o restante da droga, qual seja, em um monte de areia situado nas imediações do local da abordagem. Ato contínuo, os agentes da lei diligenciaram no local apontado por DOUGLAS e apreenderam outros 82 (oitenta e dois) "eppendorfs" de cocaína. Na delegacia, o acusado admitiu a propriedade dos entorpecentes.

O réu foi notificado nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 86) e apresentou defesa preliminar (fls. 90/94), seguindo-se a decisão que recebeu a denúncia (fls. 95/97).

Designada audiência, foi ouvida uma testemunha e interrogado o réu.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, pela fotografia de fl. 29 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 115/117, que trouxe resultado positivo para cocaína.

A autoria também é certa.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu confessou a propriedade dos entorpecentes, reservando-se, no mais, no direito de permanecer em silêncio (fls. 06/07).

Em juízo, negou a prática do crime. Disse que, no dia dos fatos, chegou do serviço, tomou banho e saiu para ir para a casa da sua tia. Atestou que estava com R\$ 50,00 no bolso e, quando voltava para casa, que fica na esquina do ponto de drogas, passou na biqueira e pegou três pinos para seu consumo, restando-lhe R\$ 20,00.

Alegou que, quando a viatura entrou, o traficante correu e os guardas o abordaram. Asseverou que informou para os guardas que estava com três pinos na mão, para seu consumo, bem como que o traficante tinha corrido. Disse que eles começaram a vasculhar a região e, como mora ali perto, sabia onde estava o restante da droga e falou para os guardas, para colaborar com a ação, mas a droga não lhe pertencia. Porém, o fato de o réu ter assumido a propriedade do entorpecente na fase policial foi corroborado pela prova produzida, não podendo ser desprezado.

Com efeito, o guarda municipal Pedro Carlos narrou que estavam em patrulhamento e se depararam com um indivíduo parado na esquina. Disse que ele demonstrou nervosismo e saiu andando, razão pela qual foi abordado. Atestou que, com ele, encontraram três porções de cocaína e R\$ 20,00 em dinheiro. Declarou que o réu confirmou que estava praticando o tráfico, que o dinheiro apreendido era produto dessa atividade e indicou onde estava o restante da droga, um monte de areia, onde encontraram outras 82 porções de cocaína, idênticas às que estavam em poder do réu. Atestou que não conhecia o réu anteriormente, mas o local já era conhecido como ponto de tráfico. Informou que o réu estava sozinho no local.

No mesmo sentido o depoimento do guarda municipal ouvido a fls. 05.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem guardas municipais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E "como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que

souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de guardas municipais é tão válida quanta outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes.

Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665). Por fim, não houve qualquer ilegalidade na conduta dos guardas municipais, já que, conforme dispõe a lei, qualquer do povo pode efetuar prisão em flagrante delito (art. 301 do Código de Processo Penal). Aliás, seria absurdo imaginar-se que os guardas municipais, informados da prática criminosa, não pudessem tomar providências para fazer cessar a infração, ficando, passivamente, no aguardo da chegada de policiais civis ou militares (cf. Apelação nº 0019493-07.2010.8.26.0068, Rel. Des. CESAR MECCHI MORALES, j. 16.12.14).

Ademais, a versão apresentada em juízo pelo réu sequer é verossímil, pois não é crível que ele tivesse indicado aos guardas o local onde estava a droga para colaborar com a ação da equipe porque morava perto do local e já sabia onde o traficante deixava o entorpecente escondido, pois, é sabido, que, assim fazendo, ficaria sujeito a represálias dos agentes do tráfico.

Enfim, o fato de os guardas civis terem apreendido três porções de cocaína em poder do réu e 82 porções da mesma droga, embaladas de maneira idêntica, no local que ele próprio indicou, aliado à confissão quanto à propriedade dos entorpecentes, conduz à certeza quanto a autoria.

A quantidade de entorpecente apreendida e a forma como estava acondicionado, aliados à apreensão de dinheiro em notas diversas e ao local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, deixam mesmo evidente que a droga se destinava ao comércio ilícito.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"Apelação. TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos relatos dos policiais e a existência de denúncias anônimas apontando o réu como sendo traficante de drogas. Quantidade e forma de acondicionamento que demonstram a destinação das drogas para a mercancia. Penas. Redução. Possibilidade - Regime prisional incensurável PARCIAL PROVIMENTO AO APELO." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0004053-31.2010.8.26.0242, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 16/02/2012, v.u.).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. - Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais que encontraram drogas em posse do réu - Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes que não deixam dúvidas da narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem dosadas que não comportam reparo. Recurso desprovido." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0038185-16.2007.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).

Impõe-se, portanto, a condenação do réu como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, cabendo anotar que, para sua configuração, não se exige qualquer ato de venda, bastando, como no caso em tela, que o agente guarde ou tenha em depósito a substância entorpecente.

2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo às circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, observo que o réu é reincidente, inclusive específico (fls. 72/73). Entretanto, essa circunstância só pode ser considerada na segunda fase de fixação da pena, evitando-se bis in idem. Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no seu valor mínimo legal.

Na segunda fase de fixação da pena, está presente a agravante da reincidência (processo n. 0012692-12.2018.8.26.0451 da 1ª Vara Criminal local - cf. certidão de

fls.72/73), razão pela qual, aplico o aumento de um sexto, resultando cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não há circunstâncias atenuantes.

Ora, o réu admitiu, extrajudicialmente, a propriedade do entorpecente, mas em momento algum confessou a prática do tráfico.

Inexistem causas de aumento e, por ser reincidente, inclusive específico, não faz jus o réu à redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, fixo o fechado, em decorrência da reincidência e por ser o único compatível com a natureza do delito, equiparado a hediondo.

Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.

Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Veda-se, por fim, o direito de apelar em liberdade, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, a qual não pode ser tornada insubsistente, sobretudo em razão da superveniência de sentença condenatória pela prática de crime equiparado a hediondo.

Porque demonstrada a origem ilícita do dinheiro apreendido, declaro o seu perdimento.

3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, CONDENANDO o réu DOUGLAS RAFAEL PONCE TELES, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no valor unitário mínimo, fixado o regime fechado para início do cumprimento da pena e vedado o direito de apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra preso e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo RÉU foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela DEFESA foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MMª. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA do(a) Dr(a). Promotor(a), dou a sentença por TRANSITADA EM JULGADO nesta data, para o MINISTÉRIO PÚBLICO.

2) Recebo o recurso interposto.

3) Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação.

4) Juntadas as razões, dê-se vista ao MP para contrarrazões de recurso.

5) Expeça-se Guia de Recolhimento e Internamento Provisória.

6) Com as razões e contrarrazões de apelação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe, salientando que o termo final da prescrição é 14/03/2034.

Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas,

visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo
JUÍZA DE DIREITO
[Assinado eletronicamente]